

1502174-39.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... peito e determinou que ele assumisse o tráfico.

Assim, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

E é certo que a perscrutação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502174-39.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502174-39.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235306/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 19921954 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

2861/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2235306 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 2861/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DOUGLAS DE ALMEIDA TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de KEVIN DOUGLAS DE ALMEIDA TORRES, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 29 de agosto de 2021, às 12h50min, na Travessa da Rua Sol Nascente, altura do número 155, Vila Dom Bosco/Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de cocaína, com peso líquido de 0,73g (setenta e três centigramas), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 82/83). O réu foi notificado (fls. 87), apresentou

sua defesa preliminar (fls. 108/116) e a denúncia foi recebida (fls. 121/123). Em audiência, foi colhida a prova oral, inclusive com o interrogatório do acusado. As partes apresentaram alegações finais em audiência.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, rejeito a preliminar de ausência de justa causa, haja vista que a demanda é viável, bem como existe lastro probatório mínimo para o início do processo criminal.

Por oportuno, anote-se que a abordagem policial foi motivada por causa provável de cometimento do crime, visto que o acusado, ao vislumbrar a presença da viatura policial, mostrou atitude suspeita, apresentando certo nervosismo. Desta forma, a abordagem do réu era medida de rigor, ante a suspeita de que estava praticando algum ato ilícito no local, suspeita que acabou se confirmando com a apreensão dos entorpecentes.

Assim, rejeito o pedido da defesa de considerar como ilícitas as provas existentes nos autos.

Superada as questões preliminares, passo, de imediato, à análise do mérito.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo auto preliminar de constatação (fls. 15/17), pelo relatório de investigação (fls. 68/69), pelo laudo definitivo (fls. 70/73), e pela prova oral coligida.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O policial militar Eder Luiz Coelho, em juízo, disse que, no dia dos fatos, ao adentrarem na rua Sol Nascente, avistaram o acusado e que, em revista pessoal, encontraram apenas certa quantia em dinheiro. Declarou que, em um cano existente próximo ao local da abordagem, encontraram mais porções de drogas. Disse que o réu confirmou ser usuário de drogas e que vendia entorpecentes em troca de drogas para consumo. Afirmou que o réu informou que foi a primeira vez que realizou a venda das drogas, pois fazia pouco tempo que tinha aceitado comercializar as substâncias. Esclareceu que tem uma escola a três quarteirões do local da abordagem. Relatou que a abordagem ocorreu, pois tinham recebido a informação de que ele estaria vendendo drogas no local.

O policial militar Marcos Paulo Figueiredo de Almeida, ouvido em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando transeuntes informaram que um indivíduo estaria comercializando drogas no local. Afirmou que avistaram o réu e que, em revista pessoal, encontraram certa quantia em dinheiro com ele. Declarou que, próximo ao local da abordagem, localizaram as porções de drogas. Relatou que o acusado afirmou que era usuário de cocaína e que tinha aceitado vender as drogas em troca de cocaína para seu uso. Esclareceu que a abordagem foi tranquila e que o réu não tentou fugir, apenas apresentou certo nervosismo quando percebeu a aproximação da viatura.

Em seu interrogatório judicial, o réu disse que, no dia dos fatos, estava parado usando as drogas e tinha guardado parte delas no cano. Confirmou que foi abordado pelos policiais e que eles encontraram as drogas que tinha deixado dentro do cano. Relatou que foi obrigado a assumir que estava comercializando as drogas, mas que, na verdade, as substâncias eram apenas para consumo. Esclareceu que não conhecia os policiais. Disse que o policial Eder deu três tapas em seu peito e determinou que ele assumisse o tráfico.

Assim, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

E é certo que a perscrutação da intenção do agente ao praticar determinada conduta constitui uma das tarefas mais árduas no âmbito da análise da adequação normativo-típica da ação do agente criminoso, notadamente porque se trata de aspecto

interior, impassível de averiguação científica.

É por isso que abalizada doutrina aponta para a necessidade de avaliação das circunstâncias do caso concreto para que se chegue a um juízo a respeito do dolo do agente. Nesse sentido:

“Em relação especificamente a prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposos.

Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios, ou seja, circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, a evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias (art. 239).” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 17ª Ed., 2014, p. 333/334)

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No caso concreto, cabe assinalar que o acusado foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro em seu bolso. Ainda, próximo ao local onde o acusado estava, foram localizados 08 (oito) microtubos de cocaína.

Em adição, importante consignar que os policiais militares reafirmaram em juízo que, no momento da abordagem, o acusado assumiu que vendia drogas no local, esclarecendo que apenas aceitou envolver-se com o tráfico, pois é usuário e, em troca de suas vendas, recebia porções de cocaína para seu consumo.

Veja-se que os agentes militares prestaram narrativas coerentes e uníssonas, contando com detalhes os fatos ocorridos, não existindo, no presente processo, nenhum indicativo de que tenham a intenção de incriminar o réu injustamente.

O testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. O simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais não conduz a que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.ª Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

O réu, por sua vez, conquanto tenha negado o tráfico em juízo, não apresentou nenhum elemento para corroborar sua versão.

Conforme os elementos colhidos, as porções de cocaína foram encontradas dentro de um cano que havia na via pública. Se o acusado fosse, de fato, simples usuário,

pouco crível que iria esconder seus pinos de entorpecentes dessa forma, em lugar exposto.

Não bastasse isso, o réu não apresentou nenhuma justificativa em relação ao nervosismo que apresentou quando percebeu a aproximação da viatura policial, nem mesmo esclareceu o que estava fazendo no local em que foi abordado.

Assim, o acusado pode até ser também usuário de drogas, mas diante das circunstâncias do caso concreto – apreensão de certa quantidade de entorpecentes, encontrada no interior de um cano existente na via pública, local em que o acusado foi abordado, além do fato de Kevin ter apresentado certo nervosismo ao ver os policiais e a afirmação dos agentes de que ele confessou informalmente o tráfico –, torna-se impossível considerar que a droga apreendida se destinava apenas ao consumo próprio, impossibilitando a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A seu turno, analisando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, conforme apontado pela defesa, não deve incidir.

A majorante visa a punir de maneira mais severa aquele que realiza a comercialização de entorpecentes em locais próximos a estabelecimentos de ensino, tendo, por isso, maior facilidade na difusão, tendo em vista a grande circulação de pessoas e o maior grau de vulnerabilidade dos que frequentam o local.

No caso dos autos, embora conste do relatório policial de fls. 68/69 que o tráfico ocorreu em local próximo à Escola Estadual Professor José Vasques Ferrari, o estabelecimento não estava em funcionamento na data e no horário em que o fato ocorreu – domingo, 29/08/2021, às 12h50min.

Assim, não há motivo para incrementar a pena dos acusados na especial circunstância dos autos.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar as penas.

#### DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não possui mais antecedentes (fls. 30/32). Os demais elementos são neutros.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa à época do fato. Todavia, como a pena já se encontra no mínimo legal, deixo de reduzi-la, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, conforme já explanado acima, não deve haver a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, vez que o delito foi praticado num domingo, dia em que as escolas encontram-se fechadas.

Por outro lado, verifico que o acusado é primário, não havendo evidências de que integre organização criminosa, tampouco se dedique a atividades criminosas, motivo pelo qual cabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Como consequência, reduzo a reprimenda em 2/3.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

#### REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Entendo que a pena imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não possui força vinculante. Por outro lado, ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, entendo que, no caso de delito de tráfico de drogas, a adoção de regime mais brando deve ser excepcional, somente possível em casos específicos.

No caso concreto, entendo preenchida a excepcionalidade da imposição de regime

inicial aberto, uma vez que, de fato, o acusado foi encontrado com drogas para fins de traficância, mas era menor de 21 anos na data do fato e não consta nenhuma outra anotação em sua folha de antecedentes. Assim, o regime aberto se impõe, até mesmo devido à quantidade de droga apreendida, que foi consideravelmente baixa - 0,73g (setenta e três centigramas) de cocaína.

Referida excepcionalidade também deve ser considerada no momento de analisar os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do presente caso, reputo adequada a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, posto que presentes os requisitos do referido preceito legal.

Nessa linha:

"Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1º Grau. Recurso ministerial. Autoria e materialidade do crime. Configuração. Negativa do réu afastada, diante dos firmes relatos prestados por policiais militares, dando conta da apreensão das drogas, cuja quantidade e variedade são indicativas da traficância. Penas. Incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Afastamento do redutor. Impossibilidade. Requisitos preenchidos pelo acusado. Pretendida fixação do regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Medidas coerentes ao quantum de pena, primariedade, bons antecedentes e gravidade em concreto do crime. Pacificação, no âmbito dos Tribunais Superiores, da tese no sentido da não hediondez do tráfico de drogas, se privilegiado nos moldes do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apelo ministerial não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500609-93.2018.8.26.0545; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, conforme disciplinado pelo juízo da Execução e (ii) limitação de final de semana.

#### DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu KEVIN DOUGLAS DE ALMEIDA TORRES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu, contudo, fica SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i) prestação de serviço à comunidade pelo tempo da condenação, conforme disciplinado pelo juízo da Execução e (ii) limitação de final de semana.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante os termos da presente sentença, bem como porque assim respondeu ao processo até o momento.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia para início da execução, certidão da sentença, bem como certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA